

1500282-02.2018.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... É PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico de drogas e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação para o tráfico. Senão vejamos.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls.06/07) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls.08/12), auto de exibição e apreensão (fls.32/33), auto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba - Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500282-02.2018.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500282-02.2018.8.26.0626

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Alexandre Prado Ferreira e outro

VISTOS.

FERNANDO ALEXANDRE PRADO FERREIRA e MATHEUS ALVES PEREIRA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Segundo narra à denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data indeterminada, porém, anteriormente ao dia 26 de dezembro de 2018, em local incerto, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, os acusados, associaram-se entre si e com terceiras pessoas ainda não identificadas, com o fim de praticar o tráfico de entorpecentes, principalmente nas imediações do "escadão" do bairro Benfica. Consta ainda que, no dia 29 de dezembro de 2018, por volta das 17h20, na Rua Luiza Brito Amaral, Jardim Britânia, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, os acusados, em concursos de pessoas, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, nas imediações de estabelecimento de ensino, traziam consigo, 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, com peso de 12,45g (doze gramas e quarenta e cinco centigramas), 30 (trinta) supositórios com crack, com o peso de 22,71g (vinte e dois gramas e setenta e um centigramas), 17 (dezessete) supositórios com cocaína, com peso de 24,47g (vinte e quatro gramas e quarenta e sete centigramas), 80 (oitenta) trouxinhas de maconha, com o peso de 277,40g (duzentos e setenta e sete gramas e quarenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2019 (fls.98/102). Os réus foram citados (fls.108) e os réus apresentaram defesa preliminar (fls.110/111 e 112/131).

No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como os réus foram interrogados, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. É PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico de drogas e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação para o tráfico. Senão vejamos.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls.06/07) e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls.08/12), auto de exibição e apreensão (fls.32/33), auto de constatação preliminar (fls.34/35), laudo pericial (fls. 86/89), e demais provas produzidas nos autos.

A autoria está comprovada.

A testemunha e Policial Militar Paulo Fernando da Silva Fumagalli disse, na delegacia, que estava em patrulhamento na companhia de seu colega de farda, pela Operação Verão, quando ao se aproximarem do "escadão" do bairro Benfica, local conhecido nos meios policiais pelo tráfico de drogas, perceberam três indivíduos em atitude suspeita, sendo que os mesmos ao perceberem a presença da viatura policial, empreenderam fuga. Informa que um dos policiais deteve o adolescente Carlos Eduardo, o qual em revista pessoal foi encontrado uma porção de maconha, a quantia de R\$10,00 (dez reais) e um aparelho celular. Relata que os réus Fernando e Matheus durante a fuga dispensaram duas sacolas plásticas, porém ambos foram detidos em seguida. Declara que na sacola que Matheus dispensou, foi encontrado 22 (vinte e duas) porções menores de maconha, uma porção maior de maconha e 67 (sessenta e sete) pedras de crack. Já na sacola em que Fernando dispensou, foi encontrado 56 (cinquenta e seis) porções de maconha, 15 (quinze) porções de crack e 17 (dezesete) eppendorfs de cocaína. Indagado sobre os fatos, os réus negaram a propriedade das drogas. Declara que o adolescente Carlos disse que é usuário de drogas e estava no local para comprar maconha. Diante os fatos foi dada voz de prisão aos réus e conduzidos até sede policial. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial.

A testemunha e Policial Militar Renato de Oliveira que também participou dos fatos narrados da denúncia na delegacia, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega. Em juízo, prestou depoimento semelhante ao da fase policial.

Em seu interrogatório o réu Matheus Alves Pereira disse, na delegacia, que foi até a "biqueira na rua da caixa d'agua" no bairro Benfica, para comprar maconha. Que ao chegar ao local perguntou sobre seu amigo Carlos Eduardo, o qual sabe que trabalha na biqueira, porém foi informado por alguns usuários que o mesmo havia ido buscar maconha, sendo assim resolveu esperar no local. Informa que após alguns minutos chegou ao local seu amigo Fernando, vulgo "mortão", o qual lhe perguntou se tinha maconha. Relata que quando Carlos chegou com a droga, apareceu uma viatura da polícia militar, sendo assim juntamente com Fernando saíram correndo. Contudo foi abordado pelos policiais, porém em revista pessoal foi encontrado a quantia de R\$28,00 (vinte e oito reais) e um aparelho celular. Declara ser usuário de entorpecentes. Em Juízo, negou a prática do delito, alegando que estava no local para comprar entorpecentes.

Em seu interrogatório o corréu Fernando Alexandre Prado Ferreira, em juízo, negou a prática do delito, alegando que estava no local para comprar entorpecentes.

Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar os réus pelo crime de tráfico de drogas.

No mais, a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347). Consigne-se, ainda, que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve

ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer, *litteris*: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10).

Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, os depoimentos deles “podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

No mesmo sentido: “(...) Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)” (HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, C UINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013).

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

O conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que os réus traziam consigo os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a respaldar uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.” (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018).

E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. “Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre

se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré. (STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial. (TJSP; Apelação Criminal 0000021- 93.2019.8.26.0556; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021); REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel. Ingresso na residência autorizado pela corré, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo rime de associação ao tráfico de drogas à corré. (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021).

Destarte, seguindo tais orientações jurisprudenciais, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre os réus. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe.

O que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, os réus tinham em depósito, os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes. Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, bem como a absolvição em relação à prática do delito previsto no artigo 35, do mesmo diploma.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Para o réu FERNANDO ALEXANDRE PRADO FERREIRA:

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que foi apreendida vasta quantidade e variedade de entorpecentes, entre os quais havia crack e cocaína, conhecidos pelo alto poder viciante e vulnerante, razão pela qual elevo a pena em 1/6, fixando a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, tendo em vista a reincidência específica, não estão preenchidos os requisitos do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Por outro lado, presente a causa de aumento de pena do art. 40, III e VI da Lei 11.343/06, uma vez que o

crime foi praticado próximo de uma escola e envolvendo menor de idade, motivo pelo qual elevo a pena em 1/5. Por isso, fixo a pena para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 em 07 anos de reclusão, além de 699 dias-multa.

Para o réu MATHEUS ALVES PEREIRA:

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que foi apreendida vasta quantidade e variedade de entorpecentes, entre os quais havia crack e cocaína, conhecidos pelo alto poder viciante e vulnerante, razão pela qual elevo a pena em 1/6, fixando a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da menoridade relativa, retornando a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 40, III e VI da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado próximo de uma escola e envolvendo menor de idade, motivo pelo qual elevo a pena em 1/5, resultando em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Por outro lado, tendo em vista que não há elementos que indiquem a participação do réu em atividades criminosas, dada a primariedade, entendo que estão preenchidos os requisitos do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 2/3. Assim, fixo a pena definitiva em 02 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Ante a ausência de informações da capacidade econômica dos réus, fixo a valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, fixo regime FECHADO, para o réu FERNANDO ALEXANDRE PRADO FERREIRA, tendo em vista a pena fixada, a reincidência específica e a presença de circunstância judicial desfavorável. Para o réu MATHEUS ALVES PEREIRA, fixo o regime SEMIABERTO, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, consistente na quantidade, variedade e lesividade das drogas apreendidas. A propósito, destaco recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que ilustra questão análoga: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MAIS GRAVOSO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 2. Na espécie, a quantidade de droga apreendida - 909g (novecentos e nove gramas) de maconha -, utilizada, inclusive, para modular a fração do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 1/2, também autoriza a conclusão de que a conduta do agravante reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que a quantidade de pena atrairia (2 anos e 6 meses), bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.959.764/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Para a aplicação da detração penal do art. 387, §2º, CPP, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistem comprovam do requisito subjetivo.

Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente pela quantidade, variedade e lesividade dos entorpecentes apreendidos, assim como pela reincidência do réu FERNANDO ALEXANDRE.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

CONDENAR o réu FERNANDO ALEXANDRE PRADO FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 07 anos de reclusão, em regime FECHADO, além do pagamento de 699 dias-multa, pela prática do crime previsto artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006;

CONDENAR o réu MATHEUS ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de 02 anos de

reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 200 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal; ABSOLVER os réus FERNANDO ALEXANDRE PRADO FERREIRA e MATHEUS ALVES PEREIRA da prática do crime previsto no artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inalterada a situação que ensejou a concessão da liberdade provisória, CONCEDO o direito de recorrer em liberdade a ambos os réus.
Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Custas ex lege.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88; o IIRGD, para as anotações de praxe; a Autoridade Policial e o Escrivão Judicial, acerca do perdimento dos objetos; expeça-se mandado de prisão e, após o respectivo cumprimento, expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva, encaminhando-se ao Juízo de Execução competente; expeça-se, ainda, Certidão de Sentença.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.I.C.

Caraguatatuba, 14 de dezembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA